

1501336-16.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE NÃO ELEVADA DE DROGA DE MENOR PODENTEIAL LESIVO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

Vara Criminal da Comarca de Itatiba

Av. Barão de Itapema, 181 - Centro - Cep: 13250-902 - Itatiba - SP

Fone: (11) 2299-1206 / e-mail: itatibacr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501336-16.2022.8.26.0544

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO,
DEBATES E JULGAMENTO

Ação: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autora: JUSTIÇA PÚBLICA

Representante do Ministério Público: Dra. Ana Carolina Martins Valente

Réu(s): KEVIN LEANDRO SOUZA LOPES

Advogado(s): Marcela Zem, OAB 309485/SP

Testemunha(s): GM Marcos Vinícius Zarantonello e GM Joel de Souza Jorge

Vítima(s): Saúde Pública

Aos 03/08/2022, às 11:00h, nesta cidade e comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, seguindo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça e na forma do Comunicado CG nº 284/2020, realizou-se audiência por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente, com a concordância das partes e envolvidos no ato processual.

Prévia e reservadamente reuniram-se o(s) acusado(s) e seu(s) Defensor(es) por intermédio de reunião, via ferramenta Microsoft Teams.

Pelas partes foi manifestada a concordância com a utilização de recurso de gravação audiovisual para a colheita dos depoimentos, dispensada a transcrição, em conformidade com os parágrafos 1º e 2º do artigo 405 do CPP e item 77.5 das NSCGJ.

Após, instalou-se formalmente a audiência, presentes na videoconferência o MM. Juiz de Direito Dr. Ezaú Messias dos Santos, o Assistente Judiciário ao final nomeado, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. Ana Carolina Martins Valente, o(s) réu(s) KEVIN LEANDRO SOUZA LOPES, o(s) advogado(s), Dr(a). Marcela Zem, OAB 309485/SP, e a(s) testemunha(s) comuns, GM Marcos Vinícius Zarantonello e GM Joel de Souza Jorge.

Ao início dos trabalhos, o MM. Juiz procedeu, primeiramente, ao interrogatório do réu com a concordância do MP e da Defesa, observadas as formalidades do artigo 185, do CPP. Após, passou a tomar o depoimento das testemunhas, que ingressaram individualmente na reunião de videoconferência, preservada a incomunicabilidade e observadas as formalidades legais. Homologada a dispensa da oitiva da testemunha comum, GM Marcos Vinicius Zarantonello.

A seguir, pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução processual e, passando-se aos debates, concedeu a palavra às partes.

A representante do Ministério Público apresentou as razões finais oralmente, tudo

gravado pelo sistema audiovisual.

A Defesa nos seguintes termos: "É forçoso para a defesa reconhecer a prática delitativa uma vez confessada pelo indiciado tanto na fase inquisitória quanto na instrução processual, assim, com base na confissão do agente a defesa requer a Vossa Excelência em alegações finais: A confissão do denunciado corroborada pelas provas e quantidade de drogas demonstram que o jovem não teria condições de adquirir tamanha variedade e quantidade de drogas o que nos traz mais um jovem aliciado pelo tráfico para sustentar seu vício. A idade e o comportamento inocente do denunciado em confessar seu ato de forma pormenorizada tem repercussão na medida em que suas afirmações preenchem os requisitos intrínsecos da confissão judicial regular (verossimilhança, certeza, clareza, persistência), sendo eficaz para atuar como atenuante da pena, nos termos do art. 65, incisos I e III, d, do Código Penal. A instrução processual não trouxe elementos para valorar a conduta pessoal e personalidade do denunciado, razão pela qual devem ser consideradas neutras, não há qualquer notícia de que se faça parte de qualquer organização criminosa. Há que se considerar, como já mencionado, a aplicação das atenuantes da idade por ser menor de 21 (vinte e um) anos bem como da confissão. No que diz respeito à vida pregressa do denunciado na seara criminal, os autos certificam também a inexistência de maus antecedentes em seu desfavor, posto que não ostenta condenações transitadas em julgado. Tem-se que o denunciado possui residência fixa residindo com seus pais na cidade de Itatiba. Analisando-se a pena in abstracto imposta ao delito, vislumbra-se a oportunidade da concessão de benesses legalmente previstas, tais como eventuais substituições de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou imposição de regime prisional nas modalidades semiaberto ou aberto ou, finalmente, a suspensão do cumprimento da pena (sursis). Tais medidas repercutirão de maneira extremamente positiva para o denunciado, visto que podem reduzir ou mesmo evitar o seu encarceramento e, por conseguinte, proporcionar a pretendida reabilitação, ressocialização e reinserção do indivíduo na sociedade. No que tange a fixação da pena de multa, considerando que o denunciado é pessoa humilde, não possuindo condições de arcar com o pagamento sem o prejuízo de sua subsistência, requer que sejam fixados os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, observa-se todas as circunstâncias e condições favoráveis a aplicação da pena em seu mínimo legal a ser cumprida em regime aberto.

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: VISTOS. KEVIN LEANDRO SOUZA LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque no dia 21 de maio de 2022, por volta das 01h00, na rua Dante Piovan e nº 18, Jardim Nardin, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, quinze porções de crack e cinquenta e cinco porções de cocaína, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, guardas municipais abordaram o réu e com ele encontraram seis porções de cocaína e R\$ 70,00 e nas proximidades, mais drogas escondidas em uma caixa de energia de uma casa. Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 40/42), o réu foi notificado e citado (fls. 124) e a defensora apresentou resposta à acusação (fls. 117/118), sendo recebida a denúncia. Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados o depoimento de uma testemunha e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, e a Defesa, em essência, pediu o reconhecimento de atenuantes e aplicação de penas alternativas. Relatado o essencial. FUNDAMENTO e DECIDO. A materialidade está demonstrada nos laudos de constatação provisória (fls. 12/14) e de exame químico-toxicológico (fls. 65/67) que resultaram positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas. Certa a autoria pela plena confissão, corroborada pela prova vocal. O réu, assim como na lavratura do flagrante, em juízo admitiu e que estava vendendo drogas no local. Disse que, passando por dificuldades financeiras, aceitou vender drogas numa biqueira para ganhar algum dinheiro. O guarda municipal confirmou a abordagem e que na revista encontraram cocaína e R\$ 70,00, admitindo o réu que estava no tráfico e em diligência pelo local foram localizadas em uma caixa de registro de uma residência mais quarenta e nove porções de cocaína e quinze porções de crack, acondicionadas

em uma sacola. Diante de tão cruel, doloroso e verdadeiro quadro, corroborada a confissão pelos demais elementos de convencimento, não resta outra solução a não ser condenar mais um desgraçado que se presta a vender drogas para enriquecer o verdadeiro traficante, que, certamente, outro imediatamente colocou no lugar porque a "lojinha" não pode parar. Reconhecidas, assim, a autoria e a materialidade, passo à dosimetria da pena. Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, relevando que a pouca quantidade de droga apreendida evidencia o comércio rasteiro para sustento do desgraçado vício, não se justifica exasperar a pena-base além do piso legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, na medida em que a circunstância atenuante genérica da confissão espontânea não têm o condão de reduzir a pena aquém da mínima cominada ao delito. Sendo o réu primário, não havendo prova de que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, faz jus à redução da pena em 2/3, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa. À mingua de parâmetros para melhor análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal. Ante as penas fixadas e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e a pouco expressiva quantidade de drogas a denotar o comércio varejista, possível a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal. No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto é o acusado primário, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo. A culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente permitiram a manutenção das penas-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime. A propósito: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE NÃO ELEVADA DE DROGA DE MENOR PODENTE CIAL LESIVO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICABILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. In casu, à mingua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se que a Corte a quo não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre a paciente e o corréu, tendo consignado que "o tipo penal previsto no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06 pressupõe a reunião de propósitos para a exploração do comércio ilegal de drogas, não sendo a estabilidade elemento de sua qualificação, estando, portanto, em desacordo com a jurisprudência firmada por esta Corte. 4. No termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 5.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei de Drogas, e tratando-se de pequena quantidade de droga de menor potencial lesivo (75,4g de maconha), é desproporcional e desarrazoada a exasperação da pena-base em 1/6, visto que não há outras circunstâncias desfavoráveis, impondo-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. 6. Tendo a pena-base sido redimensionada ao mínimo legal (5 anos), tornou-se inviável a incidência da atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal, nos termos da Súmula 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

7. Nos termos do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 8. No caso, ao contrário do firmado pelo Tribunal de origem, entende-se que a quantidade do entorpecente apreendido não se mostra elevada, fazendo jus a paciente à aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, sobretudo quando considerada sua primariedade, bons antecedentes e a ausência, no caso concreto, de elementos indicativos de que integre organização criminosa ou de que se dedique à criminalidade. 9. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é manifestamente ilegal a imposição do regime prisional mais severo com base, exclusivamente, no disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES. 10. Estabelecida a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, verificada a primariedade da agente e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, o cumprimento inicial em regime aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal. 11. Preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença condenatória, de forma a absolver a paciente pelo delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, fixar a pena-base no mínimo legal para o delito de tráfico e aplicar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, ficando a reprimenda final em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 194 dias-multa, bem para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da execução. (HC nº 355.047 - SP (2016/0112859-0); Relator Min. Ribeiro Dantas - Brasília (DF), 1º de setembro de 2016, g.n.). Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade. Por fim, em caso de descumprimento das penas substitutivas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa, na esteira do entendimento dos tribunais superiores - conforme jurisprudência acima mencionada - no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. **DISPOSITIVO.** Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar KEVIN LEANDRO SOUZA LOPES, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo as penas privativas de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do

Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo em que ficou recluso. Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça. Diante das penas alternativas impostas, não havendo mais necessidade da prisão cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado. Determino a perda do valor apreendido em favor da União. Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas. P. I. C. Itatiba, 3 de agosto de 2022. EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS. Juiz de Direito. Sentença publicada em audiência.

O MM. Juiz assina este termo em nome de todos os presentes, os quais tomaram ciência de seu conteúdo e não apresentaram impugnação, portanto, saem as partes presentes devidamente intimadas. Nada mais. Eu, ____ (Thiago André Busso), escrevente, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Link de acesso à mídia, devendo ser copiado e colado diretamente no navegador:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tbusso_tjssp_jus_br/EYSHmlTmmSpGkfiw7UFn2VABvG5QjT7lMpBZgQeZI4wgyg?e=40ctxZ